

1502733-40.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... informações sobre seu envolvimento no tráfico de drogas, vendo quando ele dispensou uma sacola contendo mais de duas centenas de flaconetes de cocaína, é óbvio que trazia consigo e tinha em depósito os entorpecentes para fins de tráfico, perfazendo-se a conduta a ele imputada na denúncia.

Incabíveis as negativas do réu sobre sua participação no tráfico de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502733-40.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502733-40.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Almeida de Deus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Marcos Almeida de Deus, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu expunha à venda, oferecia, tinha em depósito e trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, duzentas e oito porções de benzoilmetilecgonina(cocaína), todas descritas a fl. 01, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Sendo o réu notificado, apresentou defesa prévia, sendo a denúncia recebida com base no inquérito policial e regularmente citado e interrogado o réu, bem como teve apresentadas suas certidões de antecedentes criminais.

Como medida de instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação por estar demonstrada a autoria e materialidade do delito de tráfico de

entorpecentes.

Já a defesa pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas, invocando ainda matérias preliminares.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão, pois nesta serão apreciadas as questões preliminares arguidas pela defesa.

A ação penal é procedente.

Tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, perfeitamente possível atribuir ao acusado a prática do delito do art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.

A materialidade do delito vem comprovada de acordo com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 98/99 e laudo de constatação preliminar de fls. 31/32, tratando-se de 97,7 g. de cocaína em pó, distribuídos em duzentas e oito porções, evidenciando-se a intenção de tráfico por estarem prontas para serem entregues ao consumidor final.

Não se negue o fato de ter o réu procurado apresentar uma versão que o favorecesse, dizendo ter visto outros rapazes vendendo drogas e foi avisado que guardas municipais estavam chegando e dois daqueles rapazes entraram em sua casa, tendo dispensado drogas no telhado, acabando por chegarem os guardas, tendo o GM Sordi exigido o pagamento de mil reais para ser liberado, antes da chegada dos demais guardas e como estes chegaram, acabou sendo preso.

Porém, ouvidos os guardas municipais Sordi, Lombardi e Oliveira, relataram ter recebido informações anônimas de que o réu vendia tóxicos em sua casa, tendo se dirigido até lá, vendo que o acusado estava sentado em frente ao imóvel, tendo uma sacola nas mãos e buscou se levantar, tendo iniciado fuga, vindo a dispensá-la em cima do telhado a referida sacola, tendo posteriormente constatado haver nela mais de duzentos flaconetes de cocaína.

Portanto, se os guardas municipais abordaram o réu por terem informações sobre seu envolvimento no tráfico de drogas, vendo quando ele dispensou uma sacola contendo mais de duas centenas de flaconetes de cocaína, é óbvio que trazia consigo e tinha em depósito os entorpecentes para fins de tráfico, perfazendo-se a conduta a ele imputada na denúncia.

Incabíveis as negativas do réu sobre sua participação no tráfico de drogas, pois não se mostra crível a versão de que os guardas que sequer o conheciam, viessem a Juízo mentir a respeito da confissão do réu.

O crime em exame é de conteúdo múltiplo, bastando a posse de tóxicos destinado ao consumo de terceiros, não se exigindo a demonstração efetiva da mercancia por parte do réu.

Inexistiu nulidade quanto a busca pessoal feita, realizada nos moldes do art. 244 do CPP, até porque a Jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como do Colendo Supremo Tribunal Federal aponta que eventual irregularidade quanto à informação ao direito de permanecer em silêncio, é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (cf. RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 04/05/2016, RHC 61.754/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma).

Conforme recente julgado emanado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1500181-88.2021, deste Juízo, na) Mesmo que tenha ocorrido eventual ausência da informação de direito ao silêncio, isto não tem o condão de gerar automaticamente uma nulidade, salvo quando demonstrada a ausência do caráter voluntário do ato, o que não ocorreu no caso em exame.

Como é cediço, o direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não incriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à

produção de provas incriminadoras.

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio.

E nem há como se justificar uma ausência de motivos para a busca, diante da notícia recebida pelos guardas municipais de que havia tráfico de drogas no local dos fatos, tendo se dirigido até lá, tendo o réu, imediatamente, buscado homiziar uma sacola contendo centenas de porções de cocaína em pó.

E sem razão a defensoria quando se insurge contra a atividade policial, não havendo qualquer motivo para lhe conferir descrédito, mesmo porque se tratam de funcionários públicos cujos atos gozam de presunção de veracidade e não estão impedidos de depor.

Ademais, seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa e quando os chama para prestar esclarecimentos sobre seus atos, não conferir crédito às suas versões.

Farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal nesse sentido, podendo ser extraídos os seguintes julgados:

" O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"

(STF - 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas ".

(Supremo Tribunal Federal, HABEAS CORPUS Nº 74522 JULGAMENTO: 19/11/1996)

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. "

(STF - 2ª T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

Valiosas ainda as lições encontradas em julgado inserto na JTJ 268/525, sendo feita menção a outros acórdãos, encontrados em RJTJSP 13/478 e RT 733/567, no sentido de que ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável.

Também deve ser anotado qual seria o motivo para serem feitas restrições aos depoimentos de guardas municipais que participaram da apreensão de elevado volume de drogas para serem acolhidas justificativas feitas por pessoa que pretende se ver

livre de acusação pela prática de crime grave.

Daí porque não se pode imaginar que os guardas tivessem omitido do Juízo a existência de outros traficantes no local, para incriminarem o acusado, sendo bastante cômoda a acusação feita pelo réu de corrupção ativa de um dos guardas, sem ter apontado qualquer motivo relevante para que um deles assim agisse contra ele, não havendo motivos para que fosse omitido do Juízo a existência de outros traficantes, para ser incriminado injustamente o acusado.

Embora a defensoria alegue ser ilegal a prisão feita pelos guardas municipais, qualquer um do povo pode realizar prisão em flagrante (art. 301 do Código de Processo Penal), ainda mais quando ocorre crime de natureza permanente como o é o tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PRISÃO EM FLAGRANTE - Guarda municipal - Apreensão de coisas - Legalidade - Delito permanente.

A guarda municipal, a teor do disposto no parágrafo oitavo, do artigo 144, da CF, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do artigo 301 do CPP. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente.

(STJ - RHC nº 7.916 - SP - 6ª T - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJU 09.11.98).

Superior Tribunal de Justiça - STJ.

ENTORPECENTE - Tráfico - Guardas municipais que, despidos de mandado judicial, dão voz de prisão e apreendem a droga do portador ou depositário - Admissibilidade por tratar-se de crime de natureza permanente.

(STJ - RO em HC nº 9.142 - SP - 5ª T. - j. 22.02.2000 - rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJU 20.03.2000).

Desnecessário avaliar eventual nulidade na busca feita na residência do réu, pois o tóxico nem mesmo foi encontrado ali e sim em cima do telhado, após ter o réu atirado uma garrafa térmica onde se encontrava a droga.

Contudo, é certo ter a defensoria procurado argumentar que esta prova foi obtida ilicitamente, o que efetivamente não tem o condão de infirmar a tese acusatória.

E mesmo que não tenham sido obedecidas certas formalidades legais, tais como a expedição de mandado de busca, isto não elide a culpabilidade presente na conduta do réu, o qual não tinha qualquer justificativa para a posse de elevada quantidade de entorpecentes.

Ademais, em que pese o louvável esforço da defensoria, devem ser feitas duas considerações, a respeito da irregularidade na apreensão de drogas na residência do acusado.

Inicialmente deve ser indagado se a referida busca irregular teria o condão de macular toda a prova acusatória.

E obviamente a resposta é negativa, uma vez que a prova acusatória encontra supedâneo na notícia prestada pelos guardas municipais de que tinham informações de que o réu estaria vendendo drogas no local.

Tais lições são ainda obtidas segundo entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

Supremo Tribunal Federal - STF.

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - Prova ilícita - Caracterização - Ato realizado através de simples autorização Judicial, antes do advento da Lei nº 9.296/96 -

Circunstância, no entanto, que não torna nula a decisão condenatória, fundamentada

em outras provas legítimas e independentes daquela.

(STF - HC nº 76.641-7 - SP - 1ª T. - J. 01.12.98 - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 05.02.99, in RT 763/496-500)

E ainda cabe ressaltar que o delito em tela é de natureza permanente, sendo que embora fosse ilegal a entrada dos agentes policiais na residência, sem estarem munidos do respectivo mandado, a flagrância do delito tornava legítima suas ações. Tal raciocínio é amparado por elucidativo julgado emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Superior Tribunal de Justiça - STJ.

ENTORPECENTE - Tráfico - Guardas municipais que, despidos de mandado judicial, dão voz de prisão e apreendem a droga do portador ou depositário - Admissibilidade por tratar-se de crime de natureza permanente.

(STJ - RO em HC nº 9.142 - SP - 5ª T. - j. 22.02.2000 - rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJU 20.03.2000).

E deste julgado também é retirada a lição de que o tráfico de psicotrópicos proscritos é, na melhor lição doutrinária e jurisprudencial, crime permanente, o qual já está consumado com a posse pretérita da substância destinada ao consumo de terceiros, antes de qualquer tradição.

A simples guarda é que dá ao crime o caráter de permanência e é despidendo acrescentar, nos termos do artigo 303 do CPP, que o guardião da coisa ilícita está em flagrante delito enquanto não cessar essa guarda.

Legítima a entrada na casa do réu, decorre que as provas assim obtidas não são ilícitas na essência, a ponto de fulminarem a persecução penal no nascedouro. As provas indiciárias são o fumus boni juris da ação e no amplo contraditório o acusado tem a oportunidade de refutá-las.

Ademais preconiza o artigo 5º, XI, da Carta Política da República:

"Art. 5º (...)

XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou, para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial".

Como se vê, a súplica não merece acolhida, eis que é evidente a situação de flagrância, e, por se tratar de crime de natureza permanente, podiam os guardas municipais penetrarem na residência, descogitando-se de violação ao suso citado cânon constitucional.

E no referido julgado, ainda pode ser obtido outro entendimento daquela Corte de Justiça:

"Processual penal - Recurso de habeas corpus - Prisão em flagrante - Tráfico ilícito de entorpecentes.

1. Se o policial não exerce função jurisdicional, não cabe falar-se em incompetência *ratione loci*, sendo válido o auto de prisão em flagrante lavrado por autoridade de comarcas contíguas.

2. Em se tratando de crime de natureza permanente - tráfico de entorpecentes - dispensável a apresentação de mandado para efeito de prisão e apreensão da droga" (RHC 5.204/SC, rel. Min. Anselmo Santiago, publicado no DJ de 05.08.1996). (Fonte: RT nº 779/524-526)

Nesse sentido ainda, a novel posição adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da validade de busca feita em sequência a diligências feitas para se comprovar a ocorrência de tráfico de drogas:

"A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado." (AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022).

Desse modo, ficou demonstrada a materialidade do delito e respectivo nexos causal com a autoria delituosa por parte do réu, o qual trazia consigo grande quantidade de substâncias entorpecentes destinadas ao consumo de terceiros, impondo-se-lhe o decreto condenatório.

Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal,

verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, ficando a pena-base fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

O acusado é reincidente específico, como visto a fls. 135/138 e ainda incide em seu desfavor a circunstância objetiva de ter sido o crime cometido em período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, ficando elevada sua pena para seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, o unitário no mínimo legal.

O regime inicial para o cumprimento das penas deve ser o fechado, tendo em vistas as recomendações da Lei nº 8.072/90, já que se trata de delito hediondo.

Vale observar que para a fixação de regime inicial fechado, isto continua a ser estabelecido pelas regras contidas no art. 59 do Código Penal, o qual faz menção ao § 3º, do art. 33, do mesmo Codex, ou seja, não se trata apenas de se analisar a quantidade da pena, mas que este regime inicial atenda à personalidade do acusado e em que circunstâncias cometeu o delito.

Nesse sentido, os seguintes precedentes emanados do Colendo Supremo Tribunal Federal: HC 104.827, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 06/02/2013; HC 111.365, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 19/03/2013; are 675.214-agr, segunda turma, relator o ministro Gilmar Mendes, DJE de 25/02/2013; HC 113.880, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 17/12/2012; HC 112.351, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 08/11/2012; RHC 114.742, primeira turma, relator o ministro Dias Toffoli, DJE de 08/11/2012; HC 108.390, primeira turma, relatora a ministra Rosa Weber, DJE de 07/11/2012.

Contudo, poderá apelar em liberdade, em respeito ao decidido pela Superior Instância, em sede de habeas corpus.

Desde já deve ser repelida a faculdade prevista no § 4º do art. 33 da atual Lei nº. 11.343/06, pois se trata de réu reincidente e que tinha a posse de várias porções de tóxicos, de mais de uma espécie.

Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Marcos Almeida de Deus, qualificado nos autos, a pena de seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, o unitário no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.

Custas ex lege, condenando-se o réu oportunamente, ao pagamento de 100 UFESP, deixando-se de fazer a cobrança, por ora, por ser merecedor dos benefícios da assistência judiciária.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Limeira, 22 de junho de 2022.

Rogério Danna Chaib
Juiz de Direito -

Limeira, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA